

1500247-21.2022.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/10/2022

... forma, o corréu Lucas confessou a prática de tráfico, alegando dificuldades financeiras. Admite ter sido abordado em posse de dois kits de drogas pelos guardas e que tais drogas eram destinadas à venda.

Corroborando as confissões, os guardas Lindman e Anilton disseram, em juízo, que receberam delação acerca de tráfico realizado por pessoa num Pálio de cor branca em local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500247-21.2022.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500247-21.2022.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYCHARD SOARES DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face dos acusados RYCHARD SOARES DOS SANTOS e LUCAS LUAN DE SOUZA SANTOS, já qualificados nos autos, como incurso no crime do art. 33, "caput", combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.140 e 143.

Defesa Preliminar apresentada às fls.147/149.

A denúncia foi recebida, fls. 154/155.

Os réus foram citados, fls. 215 e 217.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e o acusados foram interrogados. As partes debateram. Ministério Público pediu condenação nos moldes da denúncia. Defesa, por sua vez, requereu absolvição e outros benefícios legais (fls.221/227).

É o relatório.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo auto de apreensão de fls.42, fotografias de fls.45/48 e laudo pericial de fls.115/117.

A autoria é certa.

Interrogado, o réu Rychard confessou a autoria delitiva ao admitir ter pego dois kits de drogas com o adolescente V., bem como a destinação das drogas à venda. Disse ter praticado o delito por passar por dificuldades financeiras. Esclareceu que o adolescente guardava as drogas no interior do veículo existente no local.

Da mesma forma, o corréu Lucas confessou a prática de tráfico, alegando dificuldades financeiras. Admite ter sido abordado em posse de dois kits de drogas pelos guardas e que tais drogas eram destinadas à venda.

Corroborando as confissões, os guardas Lindman e Anilton disseram, em juízo, que receberam delação acerca de tráfico realizado por pessoa num Pálio de cor branca em local já conhecido pela venda espúria. Em patrulhamento no local citado, avistaram o réu Lucas caminhando em direção ao ponto de tráfico. Em revista, lograram apreender dois kits de drogas em sua posse. Avistaram, então, o adolescente fechando o veículo Pálio mencionado pelo delator, que estava nas proximidades. O menor foi abordado, bem como Rychard que estava ao lado. Com Rychard, mais drogas idênticamente embaladas foram apreendidas. Além disso, no interior do veículo outros cinco kits foram encontrados. A chave do carro estava no bolso do inimputável.

São as provas. A condenação é de rigor.

De fato, as confissões estão confirmadas pelos testemunhos válidos dos agentes estatais, bem como pela apreensão das drogas, de dinheiro e do veículo que havia sido mencionado pelo delator (fls.42).

A destinação dos entorpecentes está evidenciada pela confissão, pela quantidade, pelo local da prisão (conhecido ponto de tráfico) e delação anterior.

Importante mencionar que a ação dos guardas se deu em patrulhamento de rotina em vias públicas municipais (ou seja, dentro de sua esfera de atribuição de vigilância de bens de domínio de referido ente federativo), bem como em situação flagrancial que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa do povo.

Nesse sentido:

"(...) Alegação de nulidade da prisão efetuada por guardas civis. Não ocorrência. - Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (STJ) (...)" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2165657-91.2022.8.26.0000; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Plantão - 00ª CJ - Capital EXTINTO - Vara Plantão - Capital Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

"No que se refere à preliminar de nulidade pela atuação da guarda municipal,

verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a referida alegação que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal que, embora ressalte ser descabida a realização de investigações de práticas de ilícitos, disso não se desume a possibilidade de, mediante notícia de crime, proceder a diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante, como ocorreu no presente caso. Com efeito, como bem observado pela Corte de origem, "os Guardas Municipais, assim como qualquer outra pessoa do povo, ao contrário do entendido externado pela nobre Defesa, pode deter alguém pela prática de crime, desde que em flagrante delito" (fl. 88), não havendo que se falar em nulidade por este fundamento. Precedentes." (STJ, AgRg no HC 748762/SP, julgamento 16/08/2022).

"É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir". (STJ, AgRg no HC 621586/SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti, 6ª. Turma, julgamento em 21/09/2021).

Havia, ainda, fundada suspeita a autorizar a busca pessoal, eis que flagrados os réus em ponto de tráfico, logo após delação apócrifa, em atitude suspeita e ao lado do veículo mencionado pelo delator.

Ademais, tratando-se de situação flagrancial, que autoriza a prisão, não há falar-se em nulidade da busca feita pelos servidores estatais. Nesse diapasão:

"(...) Guardas municipais que realizaram busca pessoal em contexto de prisão em flagrante delito. Réu que estava parado em local conhecido pelo intenso comércio de substâncias ilícitas. Réu que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e dispensou uma sacola plástica que trazia nas mãos. Comportamento suspeito que sustentou a abordagem. Justa causa para a medida. Busca necessária em contexto de preservação da integridade física dos guardas. Ilegalidade afastada. Precedentes." (TJSP; Apelação Criminal 1525695-42.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2022; Data de Registro: 05/09/2022).

No mais, irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

De fato, tratando-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado - que, segundo o Professor Damásio de Jesus, "são crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades da ação" - o delito estará consumado com a prática de um ou mais de um dos verbos nucleares, (Direito Penal, 10. Volume, Parte Geral, 6a. Edição, editora Saraiva, 1980, p. 200)

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que “para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito” (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Acerca do estado de necessidade sustentado pelos réus em autodefesa (dificuldades financeiras), entendo não deva ser acolhido.

Isso porque, como se sabe, “A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156 ...). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais (...)” (Curso de Processo Penal, 20a. Edição, ed. Saraiva, 2013, CAPEZ, Fernando, p. 410) .

Entretanto, importante ressaltar que “a prova da acusação há de ser plena e convincente, enquanto que para o acusado basta a dúvida, já que tem por si a presunção de inocência. Dispõe, com efeito, o art. 386, VI, do Código que o juiz absolverá o réu “se não existir prova suficiente para a condenação” (BARAUNA, José Roberto. Lições de Processo Penal, 2a. Edição, editora José Bushatsky. São Paulo, 1979, p. 1255)

De fato, “o acusado deve apenas atuar no sentido de apresentar dúvida razoável no espírito do julgador e não de prova plena das excludentes acima mencionadas” (fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela acusação). (DEZEM, Guilherme Madeira, Curso de Processo Penal, 2a. Edição. São Paulo, editora Revista dos Tribunais, 2016; p. 472)

Isso “nos permite deduzir que as causas de exclusão da ilicitude devem ser comprovadas pela defesa (...), mas se houver dúvida sobre a sua existência deverá o magistrado absolver o acusado (art. 386, VI, segunda parte).” (Cf. DEZEM, Guilherme Madeira. Opus citatum, p. 472).

Assim sendo, uma vez alegado o estado de necessidade, caberá à Defesa demonstrar a concorrência de seus requisitos ou condições ou, ao menos, gerar dúvida razoável sobre sua existência. São eles:

“Quatro condições, perante o Código vigente, são indispensáveis: a) existência de perigo atual para um interesse juridicamente protegido; b) não ter esse perigo sido provocado voluntariamente por quem invoca a justificativa; c) inevitabilidade do perigo; d) proporcionalidade entre a conduta do agente, ao salvar o direito, e a natureza do perigo que se lhe deparava” (GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. Vol I. Tomo I, 4a. Edição, 22a. Tiragem. Editor Max Limond. São Paulo, p.292).

Contudo, no caso em apreço, nenhuma das condições acima restou evidenciada pelos elementos probatórios dos autos. Os indícios aventados pelo agente sequer ensejam dúvida quanto a existência de estado de necessidade foram capazes de fazer emergir.

Logo, inviável acolher-se mencionada tese defensiva.

Almejando corroborar a fundamentação supra, transcrevo decisões de nossos Tribunais

refutando a aplicação da excludente alegada em casos semelhantes. Vejamos:

“Invocar estado de necessidade em tráfico de entorpecentes, sobre constituir em subversão de valores juridicamente tutelados, fere o senso de justiça da comunidade”. (JTJ, 141/399)

“Dificuldade de subsistência por meios lícitos decorrentes de doença, embora grave, não justifica apelo ao recurso ilícito, moralmente reprovável e socialmente perigoso, de se entregar o agente a negociação de tóxicos” (JUTACRIM 25/214).

Passo a dosar a reprimenda.

Os condenados são tecnicamente primários (fls.191/192 e 193/195), com a observação de que condenação pelo art. 28, da Lei de Drogas não é apta a gerar reincidente ou maus antecedentes. Vejamos:

"Na segunda etapa, também deve ser afastada a exasperação pela agravante da reincidência, pois a certidão de fl. 270 reporta condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/06. Na atual sistemática, embora preservado o caráter criminoso da posse de entorpecentes para consumo próprio, não se prevê reprimenda privativa de liberdade em caso de condenação pela conduta. Trata-se de reflexo da política criminal que orientou a elaboração da Lei 11.343/06, focada na reinserção social do viciado em drogas. As penas admitidas para o tipo (advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa) expressam essa orientação. Nesse contexto, adota-se o entendimento de que viola o princípio da proporcionalidade, além da lógica, a exasperação da sanção reclusiva de crime posterior por conta de infração que nem ao menos estipula essa espécie de reprimenda. Incoerente que a repercussão penal da condenação pelo uso de drogas seja mais gravosa do que a condenação em si". (TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000801-40.2016.8.26.0038, de relatoria do Des. Vico Mañas. São Paulo, 22 de agosto de 2018).

Confissão e menoridade não podem ensejar redução aquém do mínimo (Sumula 231, do STJ).

Reduzo a pena com base no §4º, do art.33, eis que primários e sem prova efetiva de envolvimento em orcrim.

Processos em andamento, pelo princípio da presunção de inocência, não impedem a aplicação de referido redutor.

“O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior.” (STJ, HC Nº 664.284 – ES, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, 5ª. Turma, em 21 de setembro de 2021).

A redução, entretanto, não deve ocorrer em grau máximo por conta da natureza e quantidade das drogas apreendidas. Assim sendo, reduzo apenas pela metade.

Nesse sentido:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior, firmou-se no sentido de que, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o Magistrado deve levar em consideração a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06). No caso dos autos, não se mostra desarrazoada a aplicação do quantum de redução no

patamar de 1/2, tendo em vista a quantidade da droga apreendida e as circunstâncias do delito" (STJ, HC 456110/SP, 5ª. Turma, de relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgamento em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Por derradeiro, a pena deve ser aumentada em 1/6 por conta do envolvimento do adolescente V., conforme por ele admitido em solo policial (fls.09) e confessado pelo condenados em juízo.

O regime inicial por conta da quantidade e natureza das drogas, bem como pelo envolvimento de inimputável, deve ser o semiaberto, nos moldes do parecer ministerial.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus RYCHARD SOARES DOS SANTOS e LUCAS LUAN DE SOUZA SANTOS, já qualificados nos autos, como incurso no crime do art. 33, "caput", combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, no mínimo legal.

Vedado o direito a substituição e suspensão condicional da pena por conta da natureza e quantidade das drogas e do envolvimento de menor.

Custas em 100 UFESPs.

Decreto o perdimento do numerário e do veículo apreendido, eis que usada na prática delitiva. Determino a destruição dos entorpecentes. Providencie-se o necessário.

Anotem-se. Comuniquem-se.

PRIC.

Araras, 08 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA